Capítulo 7

El sujeto que el derecho no crea

7.1. La palabra empezó siendo una máscara

La palabra que usamos para nombrar aquello que en el hombre no puede ser tocado empezó designando algo postizo. *Persona* era la máscara del actor, el rostro fingido a través del cual sonaba una voz que no era la suya; y *prósopon*, su equivalente griego, nombraba igualmente lo que se pone delante de la cara. Mauss reconstruyó con paciencia esa historia y mostró cómo el término viajó desde el teatro hasta el censo, desde el censo hasta el derecho y desde el derecho hasta la metafísica, hasta convertirse en el nombre de aquello que un hombre es cuando ya no representa a nadie (Mauss, 1938). Conviene detenerse en la ironía. El vocabulario con el que hoy declaramos que todos los seres humanos poseen un valor que ninguna autoridad les concede procede de un léxico de papeles asignados.

La ironía no es solamente etimológica. El derecho conservó durante siglos esa acepción escénica con una literalidad brutal. Para el jurista romano, la primera división del derecho de personas consistía en que todos los hombres o son libres o son esclavos; el esclavo era hombre y era cosa a la vez, sin que el ordenamiento sintiera

en ello contradicción alguna (Gayo, 1985). Un ser humano podía figurar en un inventario. La máscara se repartía y se retiraba.

Nuestra época ha invertido el gesto sin abandonar su lógica. Hoy una sociedad mercantil compra, vende, contrata, litiga, responde y sobrevive a sus fundadores, y hace todo eso sin haber sentido nunca nada. La expresión *persona jurídica* no es en ella una metáfora amable: es una descripción técnica exacta. De modo que el mismo vocabulario que negó la personalidad a hombres que la tenían se la atribuye ahora a entidades que no la tienen en ningún sentido reconocible fuera del registro mercantil. Las dos divergencias apuntan en direcciones contrarias y enseñan lo mismo: que la presencia de la palabra *persona* en una norma resuelve una pregunta sobre la norma, y ninguna pregunta sobre el mundo.

Aquí nace el problema de este capítulo. Si el derecho puede llamar persona a lo que quiera, y de hecho lo ha hecho, entonces o bien no existe nada anterior a esa decisión, y en tal caso la palabra no significa más que aquello que en cada momento el poder haya decidido que signifique, o bien existe algo que el derecho, cuando acierta, reconoce, y que sigue estando ahí cuando se equivoca. La alternativa no es escolástica. De ella depende que podamos decir, con sentido y no como mero desahogo retórico, que las leyes que despojaron de su condición a hombres concretos fueron injustas y no simplemente distintas de las nuestras.

La primera parte de este libro describió qué clase de ser es aquel que actúa: corporal, temporal, biográfico, intencional, formado por hábitos que no destruyen su libertad, relacional sin dejar de ser irreductiblemente individual. Nada de eso será reconstruido de nuevo aquí. Esa antropología se da por establecida y se toma como premisa. La pregunta que ahora se abre es de otro orden, y no se responde repitiendo la anterior: si ese es el ser que actúa, ¿qué le debemos, y quién decide que se lo debemos? Del hecho de que un

ente tenga una determinada constitución ontológica no se sigue automáticamente un estatuto normativo, y todo el peso de este capítulo consiste en recorrer, con desconfianza, cada uno de los pasos que llevan de lo uno a lo otro.

Conviene anunciar el precio de la respuesta antes de darla. Si el estatuto de sujeto se constituye por reconocimiento, entonces los derechos humanos son una concesión, y lo concedido puede retirarse sin más incoherencia que la que acompaña a cualquier cambio de política. Si, en cambio, el estatuto se descubre, hay que aceptar una tesis metafísica sobre el hombre, cargar con su prueba y responder a las objeciones formidables que la filosofía contemporánea ha acumulado contra ella. Este capítulo elige la segunda vía, y no por comodidad: es la más cara de las dos.

7.2. Lo que el derecho puede hacer con la palabra «persona»

El análisis jurídico contemporáneo ha destruido con eficacia la idea de que *ser persona en derecho* designe una propiedad simple. Hohfeld mostró que la palabra derecho encubre posiciones normativas heterogéneas, pretensiones, libertades, potestades e inmunidades, cada una con su correlativo y su opuesto, y que confundirlas produce buena parte de los razonamientos defectuosos de la práctica forense (Hohfeld, 1919). Kurki llevó ese aparato hasta el concepto mismo de personalidad y defendió que la personalidad jurídica se comprende mejor como un haz de incidentes separables que como una propiedad monolítica que se posee entera o no se posee (Kurki, 2019). Un menor tiene capacidad jurídica y no capacidad de obrar. Un declarado incapaz conserva unas posiciones y pierde otras. Una fundación es titular de patrimonio y no de honor. Un buque tuvo durante siglos, a ciertos efectos procesales, un tratamiento que

ninguna teoría razonable de la conciencia podría justificar.

De ese hallazgo se sigue algo importante y algo que no se sigue. Se sigue que la personalidad jurídica es una técnica: se atribuye por partes, se diseña según finalidades y se ajusta a necesidades institucionales que no tienen por qué coincidir con ninguna verdad sobre la naturaleza de sus destinatarios. No se sigue, en cambio, que no exista nada más. Que un instrumento sea flexible no demuestra que no haya nada que el instrumento intente medir.

La forma más rigurosa de sostener que no lo hay es la de Kelsen. En la teoría pura, la persona no es un hombre: es la personificación unitaria de un conjunto de normas, un punto de imputación construido por la ciencia jurídica para hablar con economía de un haz de deberes y facultades. La llamada persona física y la llamada persona jurídica no se distinguen, entonces, por su sustrato, porque ninguna de las dos tiene sustrato relevante para el derecho; se distinguen únicamente por la técnica de imputación que las produce (Kelsen, 1945). Hart, desde otra tradición, cerró el sistema por arriba al hacer depender la validez de una regla de reconocimiento que es, en última instancia, una práctica social efectiva de los funcionarios (Hart, 1961). En ambos casos el resultado es el mismo: el derecho no encuentra sujetos, los constituye, y preguntar por un sujeto anterior es salirse del derecho.

Esta posición no es una torpeza que pueda despacharse con una indignación moral. Es una teoría depurada, coherente, y motivada por una preocupación legítima: la de impedir que cualquier convicción sustantiva se cuele en la descripción del ordenamiento disfrazada de necesidad conceptual. Y tiene, además, una versión contemporánea considerablemente más poderosa, que no se limita al derecho.

Searle ha explicado cómo se produce la realidad institucional en general mediante reglas constitutivas de la forma «X cuenta como

Y en el contexto C», sostenidas por una intencionalidad colectiva que asigna funciones de estatus a objetos y personas. El dinero, el matrimonio, la propiedad, la frontera, el presidente de una república: nada de ello posee sus poderes en virtud de su física, sino en virtud de una aceptación colectiva continuada, y sin embargo todo ello es objetivamente real, porque la aceptación colectiva es un hecho del mundo y no una ilusión de los participantes (Searle, 1995; Searle, 2010). El constructivista serio no dice que la personalidad sea falsa. Dice que es real exactamente en el sentido en que el dinero es real. Y añade la observación antropológica que da a la tesis su fuerza empírica: la categoría de persona varía entre culturas de un modo que difícilmente encaja con el descubrimiento de una clase natural. Geertz describió una organización simbólica de la persona en Bali en la que los nombres propios se ocultan, los individuos se designan por su posición en un orden despersonalizado y la individualidad biográfica queda deliberadamente atenuada (Geertz, 1973). Si el concepto de persona tiene historia y geografía, ¿por qué no habría de tener también autoría?

A esto se suma una objeción que procede de la propia filosofía analítica y que apunta al corazón de la tesis. Locke definió a la persona como un ser pensante e inteligente, con razón y reflexión, capaz de considerarse a sí mismo como el mismo a través del tiempo, y añadió una precisión que este capítulo no puede ignorar: *persona* es un término forense, un término que pertenece al vocabulario de la imputación y del mérito (Locke, 1999). Parfit radicalizó la consecuencia: si la identidad personal consiste en continuidad psicológica y esa continuidad admite grados y ramificaciones, entonces la identidad no es lo que importa, y buena parte de nuestra retórica sobre el mismo sujeto que persiste es un residuo que la reflexión disuelve (Parfit, 1984). Frankfurt, por su parte, situó el rasgo distintivo de la persona en la capacidad de formar deseos de

segundo orden, es decir, de querer tener o no tener determinados deseos (Frankfurt, 1971). Las tres tesis son distintas, pero comparten una dirección: convierten a la persona en el resultado de una determinada actividad mental, y por tanto en algo que se tiene en la medida en que se ejerce.

La objeción, así reunida, es seria. Si la personalidad jurídica es un artefacto, si la realidad institucional se constituye por aceptación colectiva, si la categoría de persona varía culturalmente y si la identidad personal se resuelve en continuidades psicológicas graduables, la pregunta por un sujeto originario anterior a toda atribución empieza a parecer una nostalgia metafísica. Merece la pena permanecer unos párrafos dentro de esa sospecha antes de responderla, porque una respuesta que llegue demasiado pronto no habrá respondido a nada.

Y sin embargo la teoría constructivista tiene un punto en el que se rompe, y se rompe precisamente allí donde más falta hace que aguante.

Considérese qué significa aceptar que el estatuto de persona sea una función de estatus. Las funciones de estatus existen porque una colectividad las acepta. Aceptar es un acto: alguien reconoce, se compromete, sostiene una práctica. Ese alguien tiene que ser ya un sujeto capaz de intencionalidad, de compromiso y de reconocimiento antes de que la asignación se produzca, porque de lo contrario la aceptación que constituye el estatuto tendría que ser realizada por seres cuyo propio estatuto estuviera constituido por una aceptación realizada por seres cuyo estatuto, a su vez, estuviera constituido por otra aceptación anterior. La serie no se cierra. El propio Searle admite que el edificio institucional descansa sobre hechos brutos que no son a su vez institucionales; la tesis que aquí se defiende es simplemente que la personalidad está entre ellos, no porque sea físicamente bruta, sino porque es la condición de posibilidad de la

maquinaria y no uno de sus productos. Nada impide que un banco sea creado por una convención. Lo que ninguna convención puede crear es al convencionalista.

Hay además una asimetría que el ejemplo del dinero, tan útil para explicar los hechos institucionales, muestra mejor que cualquier argumento. Si mañana nadie aceptara los billetes, los billetes dejarían de ser dinero, y no habríamos cometido con ellos ninguna injusticia. Si mañana nadie aceptara a un hombre, ese hombre no dejaría de ser alguien; habríamos cometido con él la injusticia más grave que cabe cometer. La diferencia entre las dos situaciones no es de grado ni de intensidad emocional. Es lógica. En el primer caso la retirada del reconocimiento extingue el objeto de la creencia; en el segundo lo deja intacto y solo destruye la relación que manteníamos con él.

De ahí se sigue la dificultad decisiva, que es un problema interno de la teoría y no una protesta externa contra ella. Un ordenamiento que crea a sus propios sujetos no puede ser injusto con ellos, porque no hay nadie anterior a quien agraviar. Las leyes que borraron de la categoría de persona a hombres concretos no serían entonces crímenes sino ejercicios de competencia normativa, quizá desafortunados, quizá contrarios a nuestras preferencias actuales, pero no lesiones de nadie. Cuando decimos que aquellas leyes fueron injustas no estamos diciendo que contradijeran otras normas del sistema, porque en muchos casos no las contradecían; estamos diciendo que trataron como cosa a quien no lo era. Ese juicio requiere un criterio que el sistema no proporciona. Requiere, exactamente, aquello cuya existencia niega el constructivismo.

Éste es el sentido mínimo y no confesional en el que este libro se sitúa en la tradición del derecho natural. La tesis no es que todo contenido jurídico pueda deducirse de la naturaleza humana, ni que exista un código eterno del que las legislaciones sean copias

defectuosas. Es mucho más modesta y mucho más difícil de refutar: el derecho positivo no agota el dominio de las razones desde las que el derecho positivo puede ser juzgado (Finnis, 2011). Quien niega eso no está siendo riguroso; está renunciando a poder decir la única cosa que hace falta decir ante una ley que declara que ciertos hombres no cuentan.

Queda la objeción antropológica, y merece una respuesta que no la humille. Que el concepto de persona tenga historia es innegable, y Mauss la contó. Pero de la variación de un concepto no se sigue la inexistencia de su referente ni la equivalencia de todas sus versiones. Kripke enseñó que la extensión de un término de clase no queda fijada por el conjunto de criterios que en un momento dado usamos para identificar sus miembros: podemos estar equivocados sobre las marcas y estar refiriéndonos correctamente a la cosa (Kripke, 1980). Los pueblos que restringieron la condición de persona a los miembros de su tribu no tenían un concepto alternativo e incomparable; tenían el mismo concepto y una extensión mal trazada. Lo sabemos porque ellos mismos, al ampliarla, no experimentaron el cambio como la adopción de una convención nueva, sino como la corrección de un error. Nadie celebra la abolición de la esclavitud como quien celebra una reforma del sistema métrico.

7.3. Ni rendimiento ni especie

Descartada la idea de que el estatuto se constituya por atribución, hay que decir qué es aquello que se atribuye mal o bien. Y aquí se abre la trampa en la que caen casi todas las teorías contemporáneas, incluidas muchas que creen estar defendiendo la dignidad humana: la de identificar la personalidad con el ejercicio actual de ciertas capacidades.

La tentación es comprensible. Si se pregunta qué distingue a

un hombre de una piedra, la respuesta espontánea enumera actividades: piensa, habla, recuerda, decide, se representa un futuro, responde de lo que hace. De ahí a convertir esa enumeración en un criterio hay un solo paso, y ese paso lo dieron con perfecta coherencia quienes concluyeron que un ser humano que todavía no ejerce esas capacidades, o que ha dejado de ejercerlas, no es persona. Tooley lo argumentó sin eufemismos: si el derecho a la vida presupone el deseo de continuar existiendo, y el deseo presupone el concepto de uno mismo como sujeto continuado, entonces el recién nacido no satisface la condición (Tooley, 1972). Singer construyó sobre premisas análogas una ética que sustituye la frontera de la especie por la frontera de la sintiencia y de la autoconciencia, y que por ello mismo traza límites internos a la especie humana (Singer, 2011). Y a la teoría personalista le dirigió una objeción que sigue siendo la más fuerte que ha recibido: si el criterio no es una capacidad efectiva sino la pertenencia a la especie *Homo sapiens*, entonces no se ha ofrecido un fundamento moral, se ha ofrecido un privilegio biológico, indistinguible en su estructura lógica de cualquier otro favoritismo de grupo.

Hay que reconocer que esta objeción ha desarmado a muchos de sus destinatarios. Buena parte de la defensa habitual de la dignidad humana consiste, cuando se la examina, en repetir la palabra *humano* con énfasis creciente. Eso no es un argumento. Si un ser de otra especie exhibiera racionalidad reflexiva, biografía, lenguaje y responsabilidad, negarle el estatuto de persona porque su cariotipo no coincide con el nuestro sería exactamente lo que Singer denuncia. La tesis que aquí se defiende no depende de la especie como criterio último, y conviene decirlo con claridad para que la discusión no se pierda en un malentendido: la especie funciona como marca epistémica fiable de una clase de ser, no como fundamento del valor.

¿Cuál es entonces el fundamento? La respuesta se encuentra ya, en germen, en una definición muy antigua: sustancia individual de naturaleza racional. Boecio la formuló para resolver un problema teológico y Tomás la recogió para afirmar que persona nombra lo más perfecto de toda la naturaleza, esto es, lo subsistente en una naturaleza racional (Boecio, 1973; Tomás de Aquino, 2001). Lo relevante para nosotros es la estructura de la fórmula. La personalidad se predica de un individuo en virtud de la naturaleza que posee, y no en virtud del grado en que en un instante dado despliegue las operaciones propias de esa naturaleza. El sujeto no es persona porque piense; es persona porque es de la clase de seres cuya vida madura consiste en pensar, prometer, responder y hacerse cargo de sí.

Esta distinción, que suena escolástica, ha sido reconstruida en el vocabulario más exigente de la filosofía analítica contemporánea. Thompson mostró que los juicios sobre las formas de vida tienen una lógica peculiar, irreducible a la estadística: cuando decimos que el gato caza de noche o que el hombre aprende a hablar no estamos informando de una frecuencia, sino describiendo la forma de una vida, y esa descripción sigue siendo verdadera del ejemplar concreto que no caza y del niño que aún no habla (Thompson, 2008). Foot construyó sobre esa lógica una ética naturalista en la que la bondad y el defecto se predican de un viviente por referencia a lo que su forma de vida requiere, sin que ello suponga derivar valores de frecuencias observadas (Foot, 2001). Un hombre ciego no es un hombre incompleto en el sentido en que un borrador es un texto incompleto: es un hombre al que le falta algo que a un hombre le corresponde tener, y esa carencia solo es inteligible como carencia porque la forma sigue siendo la suya.

Aplicado a nuestro problema, el resultado es exacto. La capacidad radical no es una capacidad futura ni una promesa estadística.

Es la constitución presente de un ser cuya forma de operación madura incluye la razón. El bebé no es un candidato a persona que aún no ha aprobado el examen. El durmiente no deja de ser alguien durante seis horas y vuelve a serlo con el despertador. El enfermo que ha perdido la memoria no ha perdido su condición junto con ella, y el hecho de que nuestra reacción espontánea ante esa sugerencia sea el horror y no la duda es un dato filosófico, no una debilidad sentimental que la teoría deba corregir.

Al criterio funcionalista le queda todavía una carga que nunca ha logrado levantar: la del umbral. Si la personalidad depende de un nivel de capacidad, hay que decir cuál, y hay que decir por qué precisamente ahí. Ninguna de las propuestas disponibles ha conseguido justificar su frontera sin arbitrariedad, y todas comparten un rasgo estructural inquietante: producen un lado de acá y un lado de allá dentro de la propia especie humana, con la consecuencia de que la igualdad jurídica básica pasaría a depender de una medición. Una igualdad que admite grados ya no es igualdad; es una escala.

Conviene ser justo también con el flanco opuesto. Los defensores de la personalidad funcional suelen replicar que el argumento de los casos marginales es una trampa: que si aceptamos que el ser humano gravemente incapacitado conserva su estatuto pese a no ejercer las capacidades relevantes, entonces deberíamos concederlo también al animal que exhibe capacidades comparables o superiores (Dombrowski, 1997). La réplica es buena y obliga a precisar. Lo que este capítulo sostiene no es que el estatuto se conserve pese a la pérdida de capacidades, como si se tratara de una cortesía retroactiva. Sostiene que el estatuto nunca dependió de ellas, porque se predica del tipo de ser y no de su rendimiento. El animal que ejerce capacidades notables no es un ser humano que rinde poco; es un ejemplar excelente de otra forma de vida. La comparación relevante no se hace entre curvas de desempeño, sino entre formas.

Queda la cuestión de la identidad a lo largo del tiempo, que Locke abrió y Parfit llevó hasta el final. Si la persona es el sujeto de la imputación, y la imputación exige que quien responde hoy sea el mismo que actuó ayer, la teoría de la continuidad psicológica introduce una inestabilidad que ninguna doctrina de la responsabilidad puede absorber sin deformarse. Olson mostró la salida más económica: lo que somos es un animal humano, y nuestra persistencia es la persistencia de ese organismo, de modo que la continuidad psicológica es una consecuencia habitual de nuestra identidad y no su criterio (Olson, 1997). Esta posición tiene un precio, y es honesto pagarlo a la vista: obliga a decir que sobrevivimos a la pérdida total de nuestra vida mental, lo cual choca con intuiciones muy arraigadas sobre lo que nos importa. Pero el precio de la alternativa es mayor. Si la identidad no es lo que importa, tampoco lo son la promesa, la deuda, el castigo, el perdón ni la gratitud, porque las cuatro presuponen la permanencia del mismo. Ricoeur describió esa permanencia como la del sí mismo que se mantiene en la palabra dada, capaz de responder *aquí estoy* cuando otro cuenta con él (Ricoeur, 1996). Antes que una tesis metafísica, esto es la descripción de una práctica sin la cual no habría vida moral en absoluto.

7.4. Alguien a quien se puede hablar

Hasta aquí el argumento ha discurrido en tercera persona, hablando de la persona como quien habla de un objeto cuya estructura hay que determinar. Esa perspectiva es indispensable y es insuficiente, porque en la vida real nadie llega a saber que otro es alguien mediante una inspección de sus propiedades.

Strawson señaló el punto con una economía que no ha sido superada. Nuestra vida moral no se apoya en un juicio teórico sobre

la libertad de los demás, sino en un repertorio de actitudes reactivas: el resentimiento, la gratitud, la indignación, el perdón, la culpa. Esas actitudes no son consecuencias de una teoría; son la forma que tiene nuestra relación con quienes consideramos participantes, y suspenderlas equivale a adoptar frente a alguien la actitud objetiva que reservamos para lo que solo puede ser manejado, tratado o prevenido (Strawson, 1962). Uno no se indigna con la granizada. La indignación es un modo de tomarse en serio a otro.

Darwall convirtió esa observación en una tesis estructural. Existe un punto de vista de segunda persona, irreductible a la deliberación en primera persona y a la descripción en tercera, que aparece siempre que alguien dirige a otro una exigencia que pretende ser válida y que presupone en su destinatario la autoridad para exigir a su vez (Darwall, 2006). Cuando pido a alguien que retire el pie del mío, no estoy formulando una predicción sobre su conducta ni una evaluación del estado de cosas; le estoy hablando, y al hablarle le atribuyo una competencia que sería absurdo atribuir a la mesa. La reciprocidad va incorporada al acto. Quien exige se hace, en el mismo gesto, exigible.

El fenómeno tiene una densidad lingüística que conviene explotar, porque es en el lenguaje donde se hace visible con menos disputa metafísica. Austin describió una clase de emisiones que no describen nada y que hacen algo: prometer, consentir, perdonar, apelar, absolver, acusar (Austin, 1962-1971). Todas ellas tienen una condición de felicidad que suele pasar inadvertida porque nunca falla: la existencia de una contraparte capaz de recibirlas. Se puede prometer a un hombre y no a un río. No porque el río no oiga, sino porque no hay nadie ahí que quede acreedor. Cuando alguien promete a un muerto o habla a una tumba, la propia lengua registra que está haciendo otra cosa, algo que llamamos figurado, y esa reserva gramatical es una pequeña prueba de que sabemos

perfectamente cuándo hay alguien delante.

Wittgenstein condensó todo esto en una frase que resiste cualquier paráfrasis: mi actitud hacia él es una actitud hacia un alma (Wittgenstein, 1953-1988). La observación no es una tesis sobre lo que hay dentro del otro, ni una hipótesis sobre su interioridad inaccesible. Es una descripción de nuestro trato: no infiero que tengas dolor a partir de tus gestos y luego decido compadecerme; veo a alguien que sufre. Spaemann llevó esta gramática hasta su conclusión ontológica al construir toda una filosofía sobre la diferencia entre *algo* y *alguien*, y al insistir en que la personalidad no es una propiedad que un algo pudiera adquirir, sino el modo en que un ser es (Spaemann, 2006). Buber había nombrado antes la misma diferencia como la que separa la palabra fundamental *yo-tú* de la palabra fundamental *yo-ello* (Buber, 1998). Y Levinas dio a esa experiencia su formulación más extrema al describir el rostro del otro como aquello que se resiste a ser convertido en tema, y que me obliga antes de que yo haya decidido nada (Levinas, 1977).

Aquí es donde el argumento corre su riesgo mayor, y donde hay que sostener una tensión que muchos autores próximos a estas tradiciones han resuelto demasiado deprisa. Si el estatuto de alguien aparece en la interpelación, ¿no será la interpelación la que lo constituye? Esa es la lectura hegeliana del reconocimiento, y es también la puerta trasera por la que el constructivismo, expulsado en la sección anterior, podría volver a entrar vestido de fenomenología: uno sería persona porque los demás lo tratan como tal.

La respuesta está en dos hechos que cualquiera puede comprobar. El primero es que la interpelación puede errar por exceso. Un niño habla con su muñeco, un hombre solo discute con su perro, un usuario agradece a un sistema conversacional la respuesta que acaba de recibir. Nada de eso convierte al muñeco, al perro o al sistema en alguien; el trato de segunda persona se dirige a un

destinatario que en ese caso no está. El segundo es que puede errar por defecto, y esto es lo decisivo. El esclavista no trataba a su esclavo como a un tú, y su omisión no produjo el efecto de que hubiera un tú menos en el mundo; produjo el efecto de que había una injusticia más. Si el reconocimiento constituyera el estatuto, la actitud del esclavista habría sido autovalidante, y no habría manera de decir que estaba equivocado. Decimos que estaba equivocado. Y quien dice equivocado dice que había algo respecto de lo cual equivocarse.

De modo que la segunda persona no crea a su destinatario: lo descubre, y puede no descubrirlo. Es el modo en que normalmente accedemos a un hecho que no depende de que accedamos a él. La deuda es anterior al reconocimiento de la deuda, y por eso puede haber deudores que no reconozcan lo que deben.

Este resultado permite además delimitar dos afirmaciones que suelen confundirse. Que la persona sea relacional, en el sentido de que se forma, aprende y se realiza entre otros, es verdad y ya quedó establecido al describir su antropología. Que la persona sea constituida por la relación, en el sentido de que su estatuto proceda del trato ajeno, es falso, y es además la premisa oculta de las políticas de exclusión más eficaces que ha conocido la historia. Casi ninguna de ellas negó abiertamente que sus víctimas fueran seres humanos. Lo que hicieron fue dejar de hablarles.

7.5. La dignidad no es una nota alta

Llegados a este punto disponemos de un sujeto y todavía no de un valor. Sabemos, si el argumento ha funcionado, qué clase de ser es aquel al que llamamos persona y por qué su condición no depende de la atribución ajena. Falta el paso que va de ahí a la afirmación de que ese ser posee dignidad, y ese paso no puede darse por evidente,

porque la palabra dignidad se ha convertido en el término más gastado del vocabulario jurídico contemporáneo.

Conviene tomarse en serio a quienes lo dicen. Macklin sostuvo que la dignidad es un concepto inútil, un nombre elegante para lo que ya expresa con más precisión el respeto a la autonomía, y que su función real en los debates bioéticos consiste en cerrar la discusión invocando algo que nadie puede definir (Macklin, 2003). Pinker fue más lejos y la describió como un recurso retórico blando que sirve sobre todo para vetar prácticas que incomodan a quien lo invoca (Pinker, 2008). Rosen, en un estudio bastante menos beligerante, mostró que el término arrastra al menos tres significados históricos distintos, rango, valor intrínseco y comportamiento decoroso, cuya superposición explica buena parte de la confusión actual (Rosen, 2012).

La crítica acierta contra un uso muy extendido y falla contra el concepto. Acierta porque la palabra se emplea con frecuencia como comodín argumentativo, sustituto de la premisa que no se quiere explicitar. Falla porque la alternativa que propone, reducir la dignidad a la autonomía, no puede hacer el trabajo para el que se la necesita. Precisamente los casos difíciles son aquellos en los que la autonomía no está disponible: el recién nacido, el enfermo profundo, el hombre inconsciente. Si el respeto se debe a la autonomía, allí donde no hay autonomía no hay nada que respetar, y la teoría se queda sin recursos exactamente en el punto donde más falta hacen. Un concepto que sobra en los casos fáciles y falta en los difíciles no es un concepto inútil: es un concepto mal comprendido.

La formulación clásica sigue siendo la más fecunda. Kant distinguió entre lo que tiene precio, y admite por tanto un equivalente, y lo que está por encima de todo precio y no admite equivalente alguno, y exigió tratar a la humanidad siempre también como fin y nunca meramente como medio (Kant, 2012). Lo que aquí interesa

de esa doctrina no es el conjunto de sus conclusiones históricas, algunas de las cuales resultan hoy difícilmente sostenibles, sino la estructura del valor que describe: un valor que no se agrega, que no entra en el cálculo como una magnitud más y que por eso funciona como límite y no como sumando.

Hay que hacer, sin embargo, una corrección interna a Kant, y hacerla sin disimulo. Si la dignidad se funda en la autonomía racional efectivamente ejercida, la doctrina reproduce el funcionalismo que la sección anterior rechazó, y lo reproduce en su versión más elegante. La dignidad quedaría entonces vinculada a un desempeño, y volveríamos a necesitar un umbral. La reconstrucción que este capítulo propone consiste en anclar el valor no en el ejercicio de la razón sino en el modo de ser del que ese ejercicio es la operación madura. Es la misma corrección que se hizo al concepto de persona, aplicada ahora a su valor, y sin ella el edificio kantiano se derrumba por el mismo lado por el que se derrumban las teorías que dicen combatirlo.

Waldron ofrece la vía más iluminadora para entender qué clase de propiedad es la dignidad. Su tesis es que se trata de un concepto de rango, heredado del vocabulario de la nobleza y de los honores, y que la operación moderna decisiva no consistió en abolir el rango sino en universalizarlo hacia arriba: en atribuir a todo ser humano la condición que antes correspondía únicamente al noble, con el resultado de que el trato debido a cualquiera pasó a ser el que antes se debía a los pocos (Waldron, 2012). Esta lectura explica cosas que la lectura puramente axiológica no explica. Explica por qué la dignidad tiene una gramática de trato y no solo de valor, por qué se vulnera mediante la humillación y no únicamente mediante el daño, y por qué su lenguaje es tan próximo al del derecho: los rangos siempre fueron estatutos jurídicos.

De ahí procede la tesis central de esta sección, que puede formu-

larse brevemente. La dignidad no es una nota alta. No mide nada, no compara a nadie, no se gana y no se pierde con el rendimiento. Una persona puede ser más inteligente, más valiente, más culta o más productiva que otra, y ninguna de esas diferencias, todas reales, altera en lo más mínimo la prohibición de torturarla, esclavizarla o eliminarla. Si la dignidad fuera una función creciente de cualquier variable empírica, la igualdad jurídica básica sería una aproximación provisional a una jerarquía que la investigación acabaría revelando. Que rechacemos esa conclusión con tanta firmeza no es un prejuicio que la filosofía deba desactivar. Es el dato que la filosofía tiene que explicar, y la única explicación disponible es que estamos ante un estatuto y no ante una puntuación.

Korsgaard ha objetado, desde dentro del kantismo, que esta estructura no es privativa de los seres racionales, y que un ser sintiente cualquiera, en la medida en que para él las cosas pueden ir bien o mal, tiene ya fines propios y debe ser tratado como fin en sí mismo en un sentido relevante (Korsgaard, 2018). La objeción es valiosa e impide utilizar a Kant como autoridad conclusiva. La respuesta exige una distinción que se retomará en el apartado siguiente: la sintiencia funda la existencia de un bienestar, es decir, de un sujeto para el que ciertos estados son buenos o malos, y eso basta para generar razones morales genuinas; la personalidad añade una estructura reflexiva y de segunda persona que cambia la clase de consideración debida y no meramente su intensidad. Que ambas cosas sean fundamentos distintos no significa que una de ellas sea despreciable.

7.6. Del estatuto al derecho, y hasta dónde

Falta todavía una pieza, y es la que más suele omitirse: por qué de un valor se sigue un derecho. La transición no es automática.

Se podría sostener que la dignidad genera deberes en quienes la contemplan sin generar posiciones jurídicas en quien la posee, y esa posición ha sido efectivamente defendida.

La precisión hohfeldiana permite ver dónde está el problema. Un deber cuyo contenido simplemente concierne a un ente no es lo mismo que un deber dirigido a él, y solo el segundo tiene como correlativo una pretensión de la que ese ente sea titular. Prohibir la destrucción de un cuadro impone un deber respecto del cuadro, no frente al cuadro. La pregunta, entonces, es qué justifica que en el caso de la persona el deber sea dirigido.

La respuesta se sigue de lo argumentado en la cuarta sección. La estructura de segunda persona no es un accidente psicológico de nuestra relación con los demás: es la forma en que se nos presenta un ser que puede exigir y ante el que respondemos. Un ente ante el cual cabe responder es un ente frente al que se tienen deberes, y un deber frente a alguien es, en el vocabulario jurídico, el correlativo de una pretensión suya. El derecho subjetivo es lo que resulta cuando esa estructura se traduce a un lenguaje institucional capaz de operar entre agentes falibles, interesados y numerosos. No es un premio ni una concesión. Es un límite escrito.

De ahí se sigue algo, y conviene decir con la misma precisión qué es lo que no se sigue, porque la inflación del vocabulario de los derechos ha hecho más daño a su causa que cualquiera de sus críticos.

Lo que se sigue es un suelo: un conjunto de posiciones que protegen a la persona frente a su instrumentalización, su destrucción y su sometimiento, y que no pueden ser compensadas mediante la agregación de beneficios ajenos. Su nota característica es la resistencia a la ponderación. No significa que sean absolutos en cualquier circunstancia imaginable, sino que no pueden ser desplazados por el simple procedimiento de sumar utilidades del otro lado de la

balanza.

Lo que no se sigue es un catálogo. De la dignidad no se deduce un listado indefinido de prestaciones exigibles a terceros, y el salto de lo uno a lo otro suele hacerse sin argumento, aprovechando el prestigio de la primera premisa para introducir contenidos que nada tienen que ver con ella. Un derecho que impone a otros la obligación de abstenerse tiene una estructura lógica distinta de un derecho que impone a otros la obligación de proveer, y la diferencia no es de intensidad sino de forma: el primero puede ser satisfecho simultáneamente por todos, el segundo exige determinar quién paga. Esta distinción, que aquí solo queda planteada, será decisiva en los capítulos dedicados al poder político, y conviene dejarla apuntada desde el fundamento para que después no parezca una preferencia ideológica improvisada.

Tampoco se sigue que el reconocimiento jurídico sea irrelevante. Sería un error grosero deducir de la tesis defendida que las instituciones dan igual porque el estatuto no depende de ellas. Depende de ellas, y de manera dramática, todo lo demás: que el estatuto sea efectivo, que exista un tribunal ante el que invocarlo, que la lesión tenga consecuencias, que el poderoso encuentre resistencia. Una cosa es sostener que el derecho no constituye a la persona y otra muy distinta despreciar la única maquinaria que ha demostrado alguna eficacia para protegerla. La tesis es sobre el fundamento, no sobre la importancia.

Conviene, por último, someter la teoría a sus casos difíciles, porque una teoría del sujeto de derecho que solo funcione con adultos sanos y despiertos no sirve para nada.

La sociedad mercantil es el caso fácil en la dirección ascendente. Se le atribuyen posiciones jurídicas por razones de conveniencia institucional, y esa atribución es legítima y útil. Nada en ella sugiere un centro de experiencia. Su personalidad es enteramente derivada,

y por eso puede ser diseñada, limitada, levantada o extinguida por el legislador sin cometer con ella agravio alguno.

El animal sintiente es el caso que ha dominado, quizá en exceso, la discusión pública. La evidencia contemporánea obliga a conceder que numerosos animales tienen experiencias conscientes, intereses y capacidades cognitivas complejas (New York Declaration on Animal Consciousness, 2024), y cualquier teoría que los trate como mecanismos insensibles es hoy insostenible. De ello se siguen deberes reales de cuidado y prohibiciones genuinas de crueldad. No se sigue, sin una premisa adicional que nadie ha establecido, la titularidad de derechos de estructura personal. El derecho español ofrece una ilustración conceptualmente notable al definir a los animales como seres vivos dotados de sensibilidad y separarlos expresamente tanto de las personas como de las cosas (España, 2021). Esa tercera categoría no es una componenda: es la traducción jurídica de la distinción entre el fundamento del bienestar y el fundamento del estatuto.

La inteligencia artificial es el caso nuevo, y es el que mejor pone a prueba lo defendido aquí. Turing propuso sustituir la pregunta por el pensamiento de las máquinas por una prueba de desempeño conversacional, y lo hizo con plena conciencia de que estaba cambiando la pregunta (Turing, 1950). Nuestro tiempo ha construido sistemas que superan esa prueba con holgura, y la reacción social ante ellos demuestra hasta qué punto el criterio funcionalista está incorporado a nuestros hábitos: mucha gente atribuye espontáneamente interioridad a lo que responde bien. Si la personalidad fuera un rendimiento, la cuestión ya estaría resuelta y estaría resuelta en sentido afirmativo. La teoría defendida aquí obliga a decir otra cosa: la pregunta no es qué hace ese sistema, sino qué clase de ser es, y la respuesta a esa pregunta no se obtiene observando su producción verbal. La honestidad exige añadir que esto no equivale a una ne-

gativa cómoda. Significa que el criterio es más difícil de aplicar, no que el resultado esté garantizado de antemano, y quien defienda esta posición debe aceptar que la carga de determinar qué clase de ser hay ahí, si es que hay alguno, no se resuelve con desdén.

El apátrida y el esclavo son los casos que dan sentido a todo el capítulo, y son los únicos en los que la teoría no describe una zona de penumbra sino una certeza. Un hombre a quien un ordenamiento niega toda posición jurídica no se transforma por ello en otra cosa. Sigue siendo exactamente lo que era, y la prueba de que lo sigue siendo es que el ordenamiento que lo despoja necesita seguir tratándolo como sujeto para poder castigarlo, es decir, necesita imputarle actos, exigirle obediencia y presuponer en él la comprensión de una norma. Ningún régimen que haya negado la personalidad de sus víctimas ha dejado de dirigirles órdenes. Esa contradicción práctica, repetida sin excepción, es quizá el argumento empírico más fuerte de cuantos se han ofrecido en estas páginas: incluso quien niega el estatuto tiene que usarlo.

7.7. El rostro que la máscara no puso

La palabra empezó siendo una máscara y terminó nombrando lo contrario de una máscara. Ese viaje semántico contiene, comprimida, toda la historia intelectual que estas páginas han recorrido. Durante mucho tiempo se creyó que ser persona era ocupar un lugar en un reparto: tener un papel, un rango, una posición dentro de un orden que alguien administraba. La conquista moral de la modernidad consistió en descubrir que detrás del papel había alguien que no había sido puesto ahí por el reparto, y que seguía estando cuando el reparto le retiraba el nombre.

Lo que ha cambiado a lo largo del argumento no es la lista de derechos que reconocemos, sino la dirección en que se lee su fun-

damento. Si el estatuto se concediera, la pregunta política decisiva sería quién tiene competencia para concederlo, y la respuesta, cualquiera que fuese, dejaría al hombre a merced de esa competencia. Si el estatuto se descubre, la pregunta decisiva se invierte: no qué autoridad nos hace sujetos, sino qué autoridad puede legítimamente existir entre sujetos que ya lo eran antes de encontrársela.

Ésa es exactamente la pregunta con la que se abre la parte siguiente de este libro. Hemos establecido que hay alguien antes de que ninguna institución diga que lo hay. Queda por examinar qué clase de institución puede pretender mandar sobre él, con qué título, dentro de qué límites y con qué consecuencias cuando el título falla. La cuestión ya no será qué es una persona. Será qué puede hacerse legítimamente con ella.

Y conviene cerrar recuperando la imagen del principio, porque en ella está la tesis entera. Las máscaras se reparten, se heredan, se compran y se retiran; los ordenamientos llevan milenios haciéndolo y seguirán haciéndolo, unas veces con acierto técnico y otras con una crueldad que la técnica disimula. El rostro no se reparte. El derecho no fabrica rostros: se limita a decidir si los mira. Y cuando aparta la vista, no hace desaparecer a nadie. Solo se pone a sí mismo en falta.

Bibliografía del capítulo

Austin, John L. (1962-1971). *Palabras y acciones: cómo hacer cosas con palabras*. Trad. por Genaro R. Carrió y Eduardo A. Rabossi. Buenos Aires: Paidós.

Boecio (1973). «Contra Eutiques y Nestorio». En: *La consolación de la filosofía y opúsculos teológicos*. Contiene la definición clásica de persona como «naturae rationalis individua substantia». Madrid: Aguilar.

Buber, Martin (1998). *Yo y tú*. Madrid: Caparrós Editores.

Darwall, Stephen (2006). *The Second-Person Standpoint: Morality, Respect, and Accountability*. Harvard University Press. ISBN: 9780674022744.

Dombrowski, Daniel A. (1997). *Babies and Beasts: The Argument from Marginal Cases*. University of Illinois Press. ISBN: 9780252066382.

España (15 de dic. de 2021). *Ley 17/2021, de 15 de diciembre, sobre el régimen jurídico de los animales*. Boletín Oficial del Estado, núm. 300. URL: `https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/15/17`.

Finnis, John (2011). *Natural Law and Natural Rights*. 2.ª ed. Oxford: Oxford University Press.

Foot, Philippa (2001). *Natural Goodness*. Oxford: Clarendon Press.

Frankfurt, Harry G. (1971). «Freedom of the Will and the Concept of a Person». En: *Journal of Philosophy* 68.1, págs. 5-20.

Gayo (1985). *Instituciones*. Madrid: Civitas.

Geertz, Clifford (1973). *The Interpretation of Cultures*. Contiene «Person, Time, and Conduct in Bali». New York: Basic Books.

Hart, H. L. A. (1961). *The Concept of Law*. Oxford: Clarendon Press.

Hohfeld, Wesley Newcomb (1919). *Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning*. New Haven: Yale University Press.

Kant, Immanuel (2012). *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Trad. por Mary Gregor y Jens Timmermann. 2.ª ed. Cambridge University Press.

Kelsen, Hans (1945). *General Theory of Law and State*. Harvard University Press.

Korsgaard, Christine M. (2018). *Fellow Creatures: Our Obligations to the Other Animals*. Oxford University Press. DOI: 10.1093/oso/9780198753858.001.0001.

Kripke, Saul A. (1980). *Naming and Necessity*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Kurki, Visa A. J. (2019). *A Theory of Legal Personhood*. Oxford: Oxford University Press.

Levinas, Emmanuel (1977). *Totalidad e infinito: ensayo sobre la exterioridad*. Trad. por Daniel E. Guillot. Salamanca: Sígueme.

Locke, John (1999). *An Essay Concerning Human Understanding*. Ed. por Peter H. Nidditch. Libro II, cap. 27, «Of Identity and Diversity». Distinto de *Second Treatise of Government* (locke1689), ya citado en el libro. Oxford: Oxford University Press.

Macklin, Ruth (2003). «Dignity is a Useless Concept». En: *BMJ* 327.7429, págs. 1419-1420.

Mauss, Marcel (1938). «Une catégorie de l'esprit humain: la notion de personne, celle de «moi»». En: *Journal of the Royal Anthropological Institute* 68. Huxley Memorial Lecture, 1938. Reeditado en *Sociologie et anthropologie*, PUF, 1950; existen traducciones españolas de ese volumen., págs. 263-281.

New York Declaration on Animal Consciousness (2024). *The New York Declaration on Animal Consciousness*. 19 de abril de 2024. URL: `https://sites.google.com/nyu.edu/nydeclaration/declaration` (visitado 25-08-2026).

Olson, Eric T. (1997). *The Human Animal: Personal Identity Without Psychology*. Eric T. Olson, distinto de Mancur Olson (olson1965); mantener ambas claves diferenciadas. Oxford: Oxford University Press.

Parfit, Derek (1984). *Reasons and Persons*. Oxford: Clarendon Press.

Pinker, Steven (2008). «The Stupidity of Dignity». En: *The New Republic*. 28 de mayo de 2008.

Ricoeur, Paul (1996). *Sí mismo como otro*. Trad. por Agustín Neira Calvo. Madrid: Siglo XXI.

Rosen, Michael (2012). *Dignity: Its History and Meaning*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Searle, John R. (1995). *The Construction of Social Reality*. Nueva York: The Free Press.

– (2010). *Making the Social World: The Structure of Human Civilization*. Oxford: Oxford University Press.

Singer, Peter (2011). *Practical Ethics*. 3.ª ed. Cambridge University Press. DOI: `10.1017/CBO9780511975950`.

Spaemann, Robert (2006). *Persons: The Difference between 'Someone' and 'Something'*. Trad. por Oliver O'Donovan. Oxford University Press. ISBN: 9780199281817.

Strawson, P. F. (1962). «Freedom and Resentment». En: *Proceedings of the British Academy* 48, págs. 187-211. URL: `https://www.thebritishacademy.ac.uk/documents/4837/48p187.pdf`.

Thompson, Michael (2008). *Life and Action: Elementary Structures of Practice and Practical Thought*. Distinto de Evan Thompson

(VarelaThompsonRosch1991); mantener ambas claves diferenciadas. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Tomás de Aquino (2001). *Suma de teología. Parte I*. Vol. 1. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.

Tooley, Michael (1972). «Abortion and Infanticide». En: *Philosophy & Public Affairs* 2.1, págs. 37-65.

Turing, Alan M. (1950). «Computing Machinery and Intelligence». En: *Mind* 59.236, págs. 433-460.

Waldron, Jeremy (2012). *Dignity, Rank, and Rights*. Ed. por Meir Dan-Cohen. Basado en las Tanner Lectures on Human Values, 2009. Oxford: Oxford University Press.

Wittgenstein, Ludwig (1953-1988). *Investigaciones filosóficas*. Trad. por Alfonso García Suárez y Ulises Moulines. Barcelona: Crítica.